

1052889-80.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Urgência

Magistrado: GISELA AGUIAR WANDERLEY

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 2ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... que aos 31.12.2020 foi vítima de roubo com emprego de violência física, da qual sobreveio fratura na cabeça do fêmur da perna direita. Em 6.1.2021, foi submetido a cirurgia no quadril. Após, sobreveio ingresso na lista de espera para nova cirurgia (artroplastia total do quadril à direita), ainda não realizada em razão da indisponibilidade de material cirúrgico. Expõe que está em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

2ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina nº 80, São Paulo - SP - cep 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1052889-80.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1052889-80.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Urgência

Requerente:

Nilton Rodrigues dos Santos

Requerido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISELA AGUIAR WANDERLEY

Cuida-se de ação pelo procedimento comum, com requerimento de tutela provisória, ajuizada por NILTON RODRIGUES DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e do ESTADO DE SÃO PAULO, partes já qualificadas nos autos.

Na inicial, narra a parte autora, em suma, que aos 31.12.2020 foi vítima de roubo com emprego de violência física, da qual sobreveio fratura na cabeça do fêmur da perna direita. Em 6.1.2021, foi submetido a cirurgia no quadril. Após, sobreveio ingresso na lista de espera para nova cirurgia (artroplastia total do quadril à direita), ainda não realizada em razão da indisponibilidade de material cirúrgico. Expõe que está em situação de rua e com diagnóstico de coxartrose do quadril (CID 10 M169) e sequelas de fratura de fêmur (CID10 T93.1) e com fortes dores no quadril, em uso contínuo de medicamento Tramadol 50mg. Expõe a urgência da cirurgia em virtude das dores e do risco de piora clínica e déficit funcional, com invalidez.

Pleiteia, a título de tutela definitiva e inclusive em caráter antecipado, sejam os réus compelidos a realizar a cirurgia.

Requer a concessão de gratuidade de justiça.

A inicial veio acompanhada de documentos.

A tutela de urgência foi deferida, com a determinação de agendamento da cirurgia pelo Estado de São Paulo.

Citado, o Estado de São Paulo ofereceu contestação, acompanhada de documentos. Preliminarmente, aponta perda do objeto, tendo em vista que a cirurgia foi agendada para o dia 3.10.2022, bem como incompetência absoluta do Juízo. No mérito, em resumo, alega que a cirurgia não tem natureza de urgência.

Citado, o Município de São Paulo ofereceu contestação, acompanhada de documentos. Preliminarmente, aponta incompetência absoluta do Juízo. No mérito, em resumo, alega que a cirurgia não tem natureza de urgência.

Intimada, a parte autora apresentou réplica.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Quanto ao requerimento de prova pericial, deve ser indeferido. A documentação juntada aos autos é suficiente para alcançar conclusão sobre o diagnóstico da parte autora, sobre a necessidade da cirurgia e sobre a configuração de situação de urgência/emergência.

Por tais razões, à luz do art. 370, parágrafo único, do CPC, indefere-se o requerimento.

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC). Com efeito, o deslinde da controvérsia independe da produção de novas provas, pois pode ser alcançado pelo enfrentamento das questões de direito pertinentes e pela análise da documentação já carreada ao feito pelas partes na forma do art. 434 do CPC.

Quanto à preliminar de incompetência, deve ser rejeitada, tendo em vista que no caso nenhuma das partes indicou qual seria o valor da cirurgia pleiteada (proveito econômico almejado) a fim de atrair a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública com base no valor da causa.

Quanto à preliminar de perda do objeto, deve ser rejeitada.

A perda do objeto qualifica-se como o desaparecimento do bem da vida perseguido pela parte autora e a perda do interesse processual qualifica-se como o desaparecimento da necessidade ou utilidade do provimento jurisdicional, notadamente nos casos em que não há mais resistência da parte ré à pretensão da parte autora no curso da demanda. Em tais situações, não há um dos requisitos de admissibilidade da demanda (interesse processual), nos termos do art. 17 do CPC. Nenhuma de tais situações está configurada no caso ora em apreço. Com efeito, no caso, o bem da vida pleiteado foi obtido pela parte autora em razão de decisão judicial provisória, a saber, em razão da tutela provisória concedida no curso do procedimento de conhecimento. Assim, a despeito da efetivação da pretensão deduzida pela parte autora antes do julgamento definitivo do mérito, esta não foi promovida de modo voluntário pela parte ré (independentemente da intervenção jurisdicional), mas sim em razão de ordem judicial proferida com base em juízo de prelibação (cognição sumária). Não houve nenhuma forma de autocomposição do conflito (nem renúncia, nem transação, nem reconhecimento da procedência do pedido). Assim, mostra-se persistente a controvérsia entre as partes e, conseqüentemente, mostra-se necessário o exame do mérito em juízo de delibação (cognição exauriente) - até porque, em caso de revogação da tutela provisória na sentença, há responsabilidade objetiva da parte que dela se beneficiou por eventuais danos causados (teoria do risco-proveito), à luz do art. 302, I e III, do CPC. Nesse sentido, confira-se: STJ, REsp 1.770.124-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/05/2019; TJSP; Agravo de Instrumento 2261910-15.2020.8.26.0000; 9ª Câmara de Direito Privado; j. 22/02/2021; TJSP; Apelação Cível 1000538-62.2020.8.26.0066; 5ª Câmara de Direito Privado; j. 13/10/2020. Logo, no caso, é imperativo proceder ao exame do mérito, inclusive a fim de definir se é caso de confirmação ou revogação da tutela provisória.

Por tais razões, rejeita-se a preliminar.

Não há outras questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Estão presentes os requisitos de admissibilidade da demanda.

Resta, pois, analisar o mérito.

A controvérsia cinge-se à existência e à exigibilidade da obrigação do Poder Público de fornecer tratamento médico (cirurgia de quadril).

À luz do art. 196 da Constituição da República de 1988, o direito à saúde configura

direito de todos - direito fundamental de segunda dimensão (natureza positiva/prestacional) - correspectivo a dever do Estado - cujo cumprimento pressupõe política de atendimento isonômica e eficiente, o que norteia o sistema único de saúde, de caráter não contributivo, e ora regido pela Lei n. 8.080/90. Diante de tais premissas, a intervenção judicial nas políticas públicas de saúde em ações individuais, embora deva ser guiada pela tutela do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, deve ser limitada a casos de flagrante disfuncionalidade do sistema já instituído, tendo em vista que a sua implementação não se dá de forma individualizada, mas sim mediante ações coordenadas de planejamento e gestão.

Ademais, em relação a atos e decisões embasadas em questões de caráter técnico, o controle judicial deve se limitar à legalidade do ato, com deferência à discricionariedade técnica dos gestores quanto a temas complexos que demandem conhecimento científico específico (extrajurídico) - doutrina Chenery (STJ, AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP). Impõe-se um exercício de autocontenção judicial (judicial self-restraint), com evitação do apelo à metodologia fuzzy, a saber, a fundamentos vagos e indeterminados sobre questões não afetas ao Direito - notadamente questões econômicas, sociais e culturais (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Metodología fuzzy y camaleones normativos en la problemática actual de los derechos económicos, sociales y culturales. Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, III (6), 1998, p. 35-49; cf. também STJ, REsp 1.359.311/SP).

Assim, a intervenção jurisdicional deve seguir três diretrizes básicas: (1) o direito ao acesso ao serviço público de saúde, na qualidade de direito prestacional, configura um direito prima facie, vale dizer, um direito que pode ser exercido em princípio e na maior extensão possível conforme os limites fáticos e jurídicos ao caso incidentes; (2) o direito à saúde é vinculado à tutela do mínimo existencial, o qual demarca a sua fundamentalidade material e o núcleo essencial desse direito, vinculado à própria dignidade da pessoa humana e, nessa extensão, imponderável; (3) o controle judicial de políticas públicas deve se limitar aos casos de descumprimento da lei ou de atos administrativos, em atenção à insindicabilidade da discricionariedade administrativa e técnica pelo Judiciário por força do princípio da separação dos Poderes e do próprio princípio democrático. Logo, em regra, o Poder Judiciário deve compelir a Administração ao cumprimento das políticas públicas previamente formuladas pelos próprios entes federativos. Quanto ao fornecimento de tratamentos médicos e hospitalares em um regime de escassez, submetidos a fila de espera, a intervenção excepcional do Poder Judiciário depende então da demonstração de situação de emergência (situação de risco de morte ou de lesão corporal permanente ou de sofrimento intenso) ou de urgência (necessidade de tratamento cirúrgico no menor tempo possível a fim de garantir à paciente a sua subsistência digna, com a evitação das sequelas que adviriam da demora na realização do procedimento) não adequadamente enfrentadas pelo Poder Público. Tais circunstâncias atraem a necessidade excepcional de intervenção jurisdicional e, consequentemente, afastam a sua submissão à lista de espera para procedimentos eletivos confeccionada pela própria Administração Pública.

Uma vez firmadas tais premissas, em relação ao caso concreto, é relevante destacar que o caso envolve pessoa idosa, diagnosticada com coxartrose do quadril (CID 10 M169) e sequelas de fratura de fêmur (CID10 T93.1) e com fortes dores no quadril (grave comprometimento do bem-estar), em uso contínuo de medicamento Tramadol 50mg, para a qual é necessário tratamento cirúrgico, sob pena de risco de piora clínica e invalidez.

Com efeito, da leitura do relatório de fls. 12, verifica-se que a assistente social do centro de acolhimento em que o autor reside, este apresenta queixas diárias de dores. De outro lado, o relatório de fls. 13, de 27.5.2022, indica que o autor persiste com queixa de dor importante no quadril e que “a não realização do procedimento cirúrgico acarretará em desgaste progressivo da articulação com provável piora clínica e maior déficit funcional podendo acarretar inclusive em invalidez”. Apesar disso, o médico subscritor atesta que não há “previsão para

realização de procedimento (serviço aguarda recebimento de material cirúrgico necessário)".

Não há documentos que infirmem a confiabilidade do relatório supra indicado, que tem eficácia probatória nos termos da jurisprudência do STJ (por todos, cf. AgIn no REsp 1.309.793). O próprio relatório juntado com a contestação do Estado de São Paulo reforça que o paciente está sentindo dores no quadril, a reforçar que o quadro é de urgência e não meramente eletivo.

A documentação coligida à inicial, portanto, evidencia que há situação de urgência, com necessidade de cirurgia, cuja realização em prazo razoável é obrigação do Estado, regido pela Lei n. 8.080/90, razão pela qual a não implementação da aludida transferência implica violação à política pública de saúde estatuída pelo próprio Poder Público e, conseqüentemente, ao direito fundamental regido pelo art. 196 da CR/88.

No caso, vale notar que, inclusive, a obrigação já foi cumprida, conforme documentação de fls. 69-70, não impugnada pela parte autora.

Ante o exposto, confirma-se a tutela de urgência antecipada e, no mérito, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO, a fim de DETERMINAR ao ESTADO DE SÃO PAULO que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, o agendamento da cirurgia de artroplastia total do quadril à direita nos termos fixados na decisão concessiva da tutela de urgência (obrigação já cumprida cf. fls. 69-70).

Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução do mérito (CPC, art. 487, I).

Diante da sucumbência integral, condena-se o Estado de São Paulo ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, observado o escalonamento previsto no § 5º do mesmo dispositivo legal, sobre o valor da causa.

Deve ser observada a isenção legal quanto à taxa judiciária (Lei n. 11.608/03, art. 6º), a qual não afasta a obrigação de ressarcimento das custas adiantadas pela parte contrária e de responsabilidade imputada à Fazenda Pública por força da sucumbência (nesse sentido, por todos, cf. TJSP; Agravo de Instrumento 2183043-42.2019.8.26.0000; 6ª Câmara de Direito Público; j. 10/09/2019).

Dispensado o reexame necessário (CPC, art. 496, § 3º, II).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA